Aktenzeichen:
7 O 165/16

Landgericht Mannheim

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

[...]
- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte:
[...]

gegen

[...]
- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte:
[...]

wegen Patentverletzung

hat das Landgericht Mannheim - 7. Zivilkammer - durch die Vorsitzende Richterin am Landgericht [...], den Richter am Landgericht [...] und den Richter am Landgericht [...] aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 13.07.2018 für Recht erkannt:

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte seit dem 7. November 2012

   mobile Endgeräte,

   die Folgendes aufweisen:

   - einen Empfänger, der ausgelegt ist zum Empfangen eines Steuerkanalsignals von einer Basisstation, wobei das Steuerkanalsignal einen Modulations- und Codier-Schema(MCS)Index, Informationen über Ressourcenblöcke, die zur Übertragung von dem mobilen Endgerät an die Basisstation verwendet werden, und einen Kanalgüteinformationsauslöser zum Auslösen einer Übertragung eines aperiodischen Kanalgüteinformationsberichtes an die Basisstation umfasst,

   dadurch gekennzeichnet, dass die Endgeräte weiterhin umfassen:

   - einen Prozessor, der ausgelegt ist zum Bestimmen, ob der Kanalgüteinformationsauslöser gesetzt ist und ob das Steuerkanalsignal einen vorbestimmten Wert des MCS-Indexes anzeigt und eine Anzahl von Ressourcenblöcken, die kleiner oder gleich einer vorbestimmten Ressourcenblockanzahl ist, anzeigt,

   - und einen Sender, der ausgelegt ist zum Senden des aperiodischen Kanalgüteinformationsberichtes an die Basisstation ohne den aperiodischen Kanalgüteinformationsbericht mit Uplink-Shared-Channel-Daten zu multiplexen, falls die Bestimmung ein positives Ergebnis bringt

   (Anspruch 9, unmittelbare Verletzung);

   in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, in Verkehr gebracht, gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen hat;

und zwar unter Angabe

a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
c) der Menge der ausgelieferten, erhaltenen und bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden;

wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Einkaufs- und Verkaufsbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;

2. der Klägerin schriftlich in geordneter Form (gegliedert nach Kalendervierteljahren) Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 7. Dezember 2012 begangen haben und zwar unter Angabe:

a) der Mengen der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse,
b) der einzelnen Lieferungen (unter Angabe der Marken der jeweiligen Erzeugnisse sowie aller Identifikationsmerkmale wie Typenbezeichnung, Artikelbezeichnung, laufender Produktnummer), aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen (und ggf. Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer einschließlich der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,
c) der einzelnen Angebote (unter Angabe der Marken der jeweiligen Erzeugnisse sowie aller Identifikationsmerkmale wie Typenbezeichnung, Artikelbezeichnung, laufender Produktnummer), aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, - zeiten und - preisen (und ggf. Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei zum Nachweis der Angaben zu b) die entsprechenden Belege (nämlich Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen,

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu benennenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt, und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Liste enthalten ist;

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der entweder der Klägerin oder ihrer Rechtsvorgängerin, der P [...], aufgrund der seit dem 7. Dezember 2012 begangenen Handlung gemäß Ziffer I.1. entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

IV. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

V. Das Urteil ist für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung zu Ziff. I. 1 in Höhe von 50.000,00 €, zu Ziffer I. 2. in Höhe von 50.000,00 € und im Übrigen in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen behaupteter Patentverletzung (nunmehr wieder) auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Vernichtung und Rückruf in Anspruch.

Die Klage wird gestützt auf den deutschen Teil des europäischen Patents EP 2 294 737, welches die Steuersignalisierung in einem eine Basisstation und ein Endgerät umfassenden Kommunikationssystem betrifft. Das Patent wurde am 2. April 2009 durch die P [...] (fortan: P) angemeldet. Die Anmeldung wurde am 16. März 2011 veröffentlicht. Der Hinweis auf dessen Erteilung mit Wirkung u.a. für Deutschland wurde am 7. November 2012 veröffentlicht. Die Klägerin ist seit dem 03. Juli 2014 als Inhaberin des Klagepatents im Register des DPMA eingetragen.

Anspruch 9 des Klagepatents hat in der englischen Verfahrenssprache folgenden Wortlaut:

„A mobile terminal comprising:

a receiver adapted to receive a control channel signal form a base station, wherein the control channel signal comprises a Modulation and Coding Scheme, MCS, Index, information on resource blocks used for the transmission from the mobile terminal to the base station, and a channel quality information trigger for triggering a transmission of an aperiodic channel quality information report to the base station,

characterized in that the terminal further comprises

a processor adapted to determine whether the channel quality infomation trigger is set and whether the control channel signal indicates a predetermined value of t he MCS Index

and indicates a number of resource blocks that is smaller than or equal to a predetermined recource block number, and

a transmitter adapted to transmit the aperiodic channel quality information report to the base station without multiplexing the aperiodic channel quality information report with Uplink Shared Channel data, in case the determination yields a positive result."

Hinsichtlich des weiteren Inhalts der Klagepatentschrift wird auf Anlage HE-A 1 und auf die Übersetzung Anlage HE-A 1a) Bezug genommen.

Gegen das Klagepatent hat u.a. die Beklagte Nichtigkeitsklage erhoben.

Die Beklagte ist die deutsche Vertriebstochter des A-Konzerns, der Mobiltelefone weltweit herstellt und vertreibt. Die Beklagte bewirbt diese Mobilfunkgeräte in der Bundesrepublik Deutschland beispielsweise auf ihrem deutschsprachigen Facebook-Profil. Darunter sind Mobilfunkgeräte, die von der Beklagten als kompatibel mit dem Long Term Evolution-Standard („LTE-Standard") vermarktet werden, so z.B. die Modelle "[...]", "[...]", "[...]" und "[...]". Die Klägerin sieht hierin eine Verletzung von Anspruch 9 des Klagepatents.

Zu dem LTE-Standard gehören u.a. die technischen Spezifikationen des European Telecommunication Standards Instituts (ETSI), insbesondere TS 136213 (v.8.8.0, Anlage QE-A 24). Nach der ETSI IPR POLICY in der Fassung vom 22. November 2006 waren Mitglieder verpflichtet, ETSI zeitnah auf essenzielle Schutzrechte hinzuweisen. Die P brachte im Jahr 2008 im Verbund mit weiteren Unternehmen technische Vorschläge in den Standardisierungsprozess für den LTE-Standard ein (Anlage HL (A) 3 und HL (A) 4).

Seit einer ersten Kontaktaufnahme durch die Klägerin am 15. Dezember 2014 führte die Klägerin Gespräche mit der Konzernmutter der Beklagten, der B (fortan: "Muttergesellschaft der Beklagten"), über eine Lizenznahme am klägerischen [...]-Patentportfolio, zu dem auch das Klagepatent gehört. Mit Schreiben vom 3. August 2015 und vom 29. Februar 2016 (Anlage HE-A 11 / HE-A 11a) unterbreitete die Klägerin der Muttergesellschaft der Beklagten ein Lizenzangebot. Die Muttergesellschaft der Beklagten gab am 3. September 2015 ein Gegenangebot ab. Am 2. März 2016 fand ein Treffen der Vertreter der Muttergesellschaft der Beklagten und der Klägerin statt, in dem die Berechnungsmethoden der Parteien diskutiert wurden. Am 8. April 2016 machte die Muttergesellschaft der Beklagten der Klägerin ein weiteres Angebot (Anlage HL (AS) Kart 2). Am 27. Mai 2016 kam es zu einem weiteren Treffen. Mit Schreiben vom 12. August 2016 wies die Klägerin das Gegenangebot der Muttergesellschaft der Beklagten vom 8. April 2016 als zu niedrig zurück. Am 7. September 2016 wandte sich die Muttergesellschaft der Beklagten mit einem Antwortschreiben an die Klägerin. Unter dem 27. September 2016 erhob die Klägerin die hiesige Klage gerichtet auf Auskunft,

Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung. Bei einem Treffen am 14. Dezember 2016 machte die Muttergesellschaft der Beklagten der Klägerin ein weiteres Lizenzangebot. Mit Schriftsatz vom 30. Januar 2017 hat die Klägerin die Klage um Unterlassungs-, Vernichtungs- und Rückrufanträge wegen Verletzung des Klagepatents erweitert. Die mit der Klageerweiterung angekündigten Anträge hat die Klägerin mit der Replik vom 27. März 2017 zurückgenommen. Mit Schreiben vom 21. April 2017 übermittelte die Klägerin der Muttergesellschaft der Beklagten ein weiteres Lizenzangebot. Am 16. Februar 2018 wurde der Muttergesellschaft der Beklagten durch die Klägerin noch ein weiteres Lizenzangebot unterbreitet (Anlage QE-A 8). Mit Schriftsatz vom 23. Februar 2018 wurde dies der Kammer zur Kenntnis gebracht. Nachdem die Muttergesellschaft der Beklagten, wie von der Klägerin gefordert, eine Verschwiegenheitsvereinbarung (Non Disclosure Agreement, NDA) unterzeichnet hatte, stellte die Klägerin der Muttergesellschaft der Beklagten mit Schreiben vom 11. April 2018 mit Dritten geschlossene Lizenzverträge über das [...]-Patentportfolio zur Verfügung und setzte eine einwöchige Frist zur Annahme des Lizenzangebots bis zum 18. April 2018. Mit Schreiben vom 18. April 2018 (Anlage QE-A 12) teilte die Muttergesellschaft der Beklagten der Klägerin mit, dass sie zu einer Analyse der Drittlizenzverträge noch nicht in der Lage gewesen sei, da ein externer Experte hinzugezogen werden müsse. Man werde sich melden, sobald die Stellungnahme des Experten vorliege. Mit Schreiben vom 24. April 2018 (Anlage QU-A 13) forderte die Klägerin die Muttergesellschaft der Beklagten auf, bis zum 7. Mai 2018 auf das Lizenzangebot zu reagieren. Mit Schreiben vom 2. Mai 2018 (Anlage QU-A 14) wandte sich die Muttergesellschaft der Beklagten an die Klägerin und teilte mit, dass man der Klägerin antworten werde, sobald die Überprüfung beendet sei. Mit Schriftsatz vom 15. Mai 2018 hat die Klägerin die Klage um die Unterlassungs-, Vernichtungs- und Rückrufanträge erweitert. Der Beklagten, welche die Klageerweiterung von der Gegenseite per E-Mail vorab erhalten hatte, wurde die Klageerweiterung am 22. Mai 2018 zugestellt. Auf Antrag der Beklagten auf Fristverlängerung bis zum 29. Juni 2018 wurde die gesetzte Frist zur Erwiderung auf die Klageerweiterung bis zum 27. Juni 2018 verlängert. Ein Gegenangebot der Beklagten vom 25. Juni 2018 hat die Klägerin abgelehnt.

Die Klägerin behauptet, sie habe das Klagepatent von P erworben und diese habe vor der Übertragung des Klagepatents entstandene Ansprüche an die Klägerin abgetreten.

Die standardkonformen mobilen Endgeräte machten von der Lehre des Patentanspruchs 9 wortsinngemäß Gebrauch.

Der Klägerin sei nicht bekannt, wann die frühere Patentinhaberin das Klagepatent ETSI erstmals bekannt gegeben habe. Sollte dies tatsächlich erst am 25. Oktober 2010 erfolgt sein, liege hierin keine betrügerische Absicht. Es werde mit Nichtwissen bestritten, dass bei Kenntnis von der Patentanmeldung ETSI mit hoher Wahrscheinlichkeit eine alternative Lösung in den Standard aufgenommen hätte.

Die Klägerin beantragt zuletzt:

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 E - ersatzweise Ordnungshaft - oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollziehen ist, zu unterlassen:
   mobile Endgeräte
   in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,
   die Folgendes aufweisen:
   einen Empfänger, der ausgelegt ist zum Empfangen eines Steuerkanalsignals von einer Basisstation, wobei das Steuerkanalsignal einen Modulations- und Codier-Schema(MCS)Index, Informationen über Ressourcenblöcke, die zur Übertragung von dem mobilen Endgerät an die Basisstation verwendet werden, und einen Kanalgüteinformationsauslöser zum Auslösen einer Übertragung eines aperiodischen Kanalgüteinformationsberichtes an die Basisstation umfasst,
   dadurch gekennzeichnet, dass die Endgeräte weiterhin umfassen:
   einen Prozessor, der ausgelegt ist zum Bestimmen, ob der Kanalgilteinformationsauslöser gesetzt ist und ob das Steuersignal einen vorbestimmten Wert des MCS-Indexes anzeigt und eine Anzahl von Ressourcenblöcken, die kleiner oder gleich einer vorbestimmten Ressourcenblockanzahl ist, anzeigt,

   und einen Sender, der ausgelegt ist zum Senden des aperiodischen Kanalgüteinformationsberichtes an die Basisstation ohne den aperiodischen Kanalgüteinformationsbericht mit Uplink-Shared-Channel-Daten zu multiplexen, falls die Bestimmung ein positives Ergebnis bringt
   (Anspruch 9, unmittelbare Verletzung);

2. wie erkannt (Tenor I.1)

3. wie erkannt (Tenor I.2)

4. die in der Bundesrepublik Deutschland jeweils in ihrem unmittelbaren und/oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindlichen, unter Ziffer I.1. bezeichneten Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von der Klägerin zu benennenden oder zu beauftragenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben;

5. die unter Ziffer I. 1. bezeichneten, seit dem 7. November 2012 in Verkehr gebrachten und im Besitz Dritter befindlichen Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits bezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird und endgültig zu entfernen, indem die Beklagte die erfolgreich zurückgerufenen Erzeugnisse wieder an sich nehmen.

II. wie erkannt.

Die Beklagte beantragt,

die Klage kostenpflichtig abzuweisen;

hilfsweise, den Rechtsstreit gemäß § 148 ZPO bis zur Entscheidung des Bundespatentgerichts im Nichtigkeitsverfahren über den Rechtsbestand auszusetzen.

Die Beklagte trägt vor:

Aus den LTE-Spezifikationen ergebe sich eine Benutzung der patentgemäßen Lehre nicht. Ob das Telefon das Vorhandensein bzw. die Werte der Parameter Kanalgüteinformationsauslöser, MCS-Index und Anzahl der Ressourcenblöcke bestimmt oder nicht, sei nicht offenbart. Soweit die Klägerin eine Rückberechnung des Wertes RIV auf die „total number of allocated PRBs (N_{PRB})“ vortrage, bringe sie hierfür keine Belege.

Das Klagepatent sei aus kartellrechtlichen Gründen nicht durchsetzbar, weil seine Aufnahme in den geltend gemachten Standard TS 136.213 (Anlage HE-A 5) auf einem so genannten "Patent Ambush" beruhe. Die Patentanmelderin P habe ihre Offenbarungspflicht verletzt. Sie habe erstmals mit Erklärung vom 25. Oktober 2010 (Anlage HL (A) 6) ETSI mitgeteilt, dass das Klagepatent standardessentiell sei. Die mangelnde rechtzeitige Offenbarung des Klagepatents gegenüber ETSI sei kein Einzelfall. In jedem Verfahren innerhalb des derzeit laufenden Streitkomplexes zwischen den Parteien vor der Kammer — neben dem hiesigen Verfahren noch die Verfahren 7 O 19/17, 7 O 20/17 und 7 O 73/17 — sei aufgezeigt worden, dass keine rechtzeitige Deklarierung der jeweiligen Klagepatente erfolgt sei. Dies zeige, dass es offenbar eine bewusste Strategie des Unternehmens gewesen sei, Art. 4.1 der ETSI IPR Policy zu missachten und die Schutzrechte erst dann zu offenbaren, als die Technologien bereits final in die Standards aufgenommen waren.

Den geltend gemachten Ansprüchen auf Unterlassung der Patentverletzung sowie Rückruf und Vernichtung der angeblich patentverletzenden Erzeugnisse stehe der FRAND-/Kartellrechtseinwand entgegen. Die Klägerin missbrauche mit der Durchsetzung der genannten Ansprüche gegen die lizenzbereite Beklagte ihre marktbeherrschende Stellung und verstoße damit gegen Art. 102 Abs. 1 AEUV und §§ 18, 19 GWB.

Die Nichtigkeitsklage werde mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit Erfolg haben, so dass der Rechtsstreit hilfsweise auszusetzen sei.

Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die Klägerin ist als im Register eingetragene Alleininhaberin des Klagepatents prozessführungsbefugt und auch materiell hinsichtlich der erhobenen Ansprüche legitimiert (I.). Da die angegriffenen Ausführungsformen von der Lehre des geltend gemachten, unabhängigen Patentanspruchs 9 (II.) unmittelbar wortsinngemäß Gebrauch machen (III.) und eine Aussetzung des Rechtsstreits nicht angezeigt ist (VI.), ist die Beklagte im beantragten Umfang zu Auskunft und Rechnungslegung zu verurteilen und ihre Schadensersatzverpflichtung festzustellen (IV.). Die auf Unterlassung, Rückruf/Entfernung aus den Vertriebswegen und Vernichtung gerichteten Anträge sind hingegen abzuweisen, weil die Klägerin insoweit an der Anspruchsdurchsetzung aus kartellrechtlichen Gründen gehindert ist (V.).

I. Prozessführungsbefugnis und Aktivlegitimation

Die Klägerin ist seit 3. Juli 2014 alleinige im Patentregister eingetragene Inhaberin des Klagepatents und als solche formell zur Prozessführung (Art. 2 Abs. 2, Art. 64 Abs. 1 EPÜ iVm § 30 Abs. 3 S. 2 PatG) sowie materiell (Art. 64 Abs. 3 EPÜ iVm §§ 139 ff. PatG) zur Durchsetzung der gegen die Beklagte erhobenen Ansprüche legitimiert.

Die Klägerin ist jedenfalls aufgrund des mit P abgeschlossenen „Confirmatory Patent Rights Assignment" („CPRA") vom 20./25. April 2017 (Anlage HE-A 25), in welchem die Übertragung des Patents und die Abtretung bereits entstandener Ansprüche vorsorglich nochmals vereinbart wurde, Gläubigerin entsprechender Ansprüche. Auf den nur noch hilfsweise geltend gemachten Übertragungsakt aus dem Jahr 2013 kommt es vor dem Hintergrund nicht an.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGHZ 197, 196 Rn. 51 ff - Fräsverfahren) hat die Eintragung im Patentregister keinen Einfluss auf die materielle Rechtslage. Sie wirkt weder rechtsbegründend noch rechtsvernichtend. Ihre Legitimationswirkung ist beschränkt auf die Befugnis zur Führung von Rechtsstreitigkeiten aus dem Patent. Daraus ergibt sich, dass für die Sachlegitimation im Verletzungsrechtsstreit nicht der Eintrag im Patentregister, sondern die materielle Rechtslage maßgeblich ist. Allerdings kommt der Eintragung im Patentregister für die

Beurteilung der Frage, wer materiell-rechtlich Inhaber des Patents ist, eine erhebliche Indizwirkung zu (BGH, aaO Rn. 58). Denn nach § 30 Abs. 3 Satz 1 PatG darf das Patentamt eine Änderung in der Person des Patentinhabers nur dann im Register vermerken, wenn sie ihm nachgewiesen wird. Angesichts dessen bedarf es in einem Verletzungsrechtsstreit regelmäßig keines weiteren Vortrags oder Beweisantritts, wenn sich eine Partei auf den aus dem Patentregister ersichtlichen Rechtsstand beruft. Macht daher die Beklagtenseite geltend, die materielle Rechtslage weiche vom Registerstand ab, so muss sie konkrete Anhaltspunkte aufzeigen, aus denen sich die Unrichtigkeit ergibt (BGH, aaO Rn. 59 f). Sie muss konkret darlegen, warum der im Register eingetragene Kläger tatsächlich nicht Inhaber des Patents sein soll. Dass der Übergang des Patents auf den Kläger seitens des Beklagten lediglich mit Nichtwissen bestritten wird, genügt nicht.

Insoweit hat die Beklagte lediglich Zweifel an der Wirksamkeit des CPRA dahingehend geäußert, im Rahmen der ursprünglichen Patentübertragungsvereinbarung sei - anders als bei CPRA - noch eine nicht identifizierte dritte Partei beteiligt gewesen. Damit hat die Beklagte die Wirksamkeit - ebenso wie jene der zugleich erklärten Abtretung von bereits entstandenen Schadensersatz- und Bereicherungsansprüchen - allerdings nicht wirksam - auch nicht mit Nichtwissen - bestritten. Darauf hat die Kammer bereits mit dem im Parallelverfahren ergangenen Urteil vom 19.01.2018 (Az. 7 O 20/17, S. 34) hingewiesen.

Nach Ziff. 2 des CPRA ist - schon ungeachtet des für das Übertragungsgeschäft maßgeblichen Schutzlandprinzips - für dessen Wirksamkeit deutsches Recht maßgeblich. Dabei ist allerdings hinsichtlich der Frage der Vertretungsmacht eigenständig anzuknüpfen. Da diese nach klägerischem Vortrag organschaftlich begründet ist, unterliegt sie japanischem Recht. Die Beklagte hat den Klägervortrag nicht bestritten, wonach das mit einem registrierten Siegel versehene Dokument mit dem darin enthaltenen Inhalt wirksam durch eine dazu befugte Person errichtet worden sei (§ 293 ZPO). Die bloßen beklagtenseits geäußerten Zweifel hinsichtlich der noch im ersten Übertragungsakt involvierten dritten Person vermögen ebenfalls der Wirksamkeit des CPRA nicht entgegenzustehen. Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits ist allein das Klagepatent, an welchem eine dritte Partei nie Rechte innehatte, jedenfalls wird solches nicht vorgetragen. Vor diesem Hintergrund hätte die Beklagte substantiiert vortragen müssen, weshalb es nach ihrer Auffassung der Mitwirkung einer dritten Partei zu dessen Übertragung sowie der Abtretung hierauf gegründeter Ansprüche bedurfte. Hierauf hat die Kammer bereits mit Urteil vom 19.01.2018 (Az. 7 O 20/17, S. 34) hingewiesen.

II. Klagepatent

1. Die Erfindung gemäß dem Klagepatent betrifft die Steuersignalisierung in einem aus Basisstation und Endgerät bestehenden Kommunikationssystem. Im Stand der Technik war bekannt, dass die Mobilstation der Basisstation Rückmeldungen zu der Übertragungsqualität auf dem Downlink-Übertragungskanal (PUSCH Physical Uplink Shared Channel), nämlich sog. Kanalgüteinformation (Channel Quality Indication, CQI) liefert (Abschnitt [0031] der Klagepatentschrift). Gegenstand des Klagepatents sind sog. aperiodische Qualitätsreports. Diese werden von der Basisstation nach Bedarf angefordert.

   Nach der Beschreibung des Klagepatents werden üblicherweise, nämlich in dem Fall, dass ein Datenpuffer der User-Einheit nicht leer ist, Anwenderdaten (welche dem physikalischen Kanal PUSCH über einen Transportkanal, den UpLink-Shared Channel, UL-SCH zugeführt werden) und CQI miteinander gemultiplext (Abschnitt [0041]). Nach der Beschreibung des Klagepatents ist es selbst in dem Fall, in dem der Datenpuffer am Endgerät nicht leer ist, wünschenswert, den Kanalgüteinformationsbericht zu senden, ohne ihn mit Uplink-Shared-Channel-Daten zu multiplexen. Dies führt nach der Beschreibung des Klagepatents zu einer verbesserten Fehlerresilienz (Abschnitt [0043]).

   Vor diesem Hintergrund schlägt das Klagepatent ein mobiles Endgerät gemäß den Merkmalen des Anspruchs 9 vor, welche sich wie folgt gliedern lassen:

   A mobile terminal comprising:

   Mobiles Endgerät, umfassend

   1. a receiver adapted to receive a control channel signal form a base station, wherein the control channel signal comprises

      einen Empfänger, der ausgelegt ist zum Empfangen eines Steuerkanalsignals von einer Basisstation, wobei das Steuerkanalsignal umfasst

   1.1 a channel quality information trigger for triggering a transmission of an aperiodic channel quality information report to the base station,

einen Kanalgüteinformationsauslöser zum Auslösen einer Übertragung eines aperiodischen Kanalgüteinformationsberichtes an die Basisstation,

1.2 a Modulation and Coding Scheme, MCS index, [and]

einen Modulations- und Codier Schema- (MSC) Index, [und]

1.3 information on resource blocks used for the transmission from the mobile terminal to the base station

Information über Ressourcenblöcke, die zur Übertragung von dem mobilen Endgerät an die Basisstation verwendet werden,

2. einen Prozessor, der ausgelegt ist zum Bestimmen,
a processor adapted to determine

2.1 whether the channel quality infomation trigger is set and

ob der Kanalgüteinformationsauslöser gesetzt ist und

2.2 whether the control channel signal indicates a predetermined value of the MCS Index and

ob das Steuerkanalsignal einen vorbestimmten Wert des MCS-Indexes anzeigt und

2.3 indicates a number of resource blocks that is smaller than or equal to a predetermined resource block number,

[ob das Steuerkanalsignal] eine Anzahl von Ressourcenblöcken, die kleiner oder gleich einer vorbestimmten Ressourcenblockanzahl ist, anzeigt,

3. a transmitter adapted to transmit the aperiodic channel quality information report to the base station without multiplexing the aperiodic channel quality information report with Uplink Shared Channel data, in case the determination yields a positive result.

und einen Sender, der ausgelegt ist zum Senden des aperiodischen Kanalgüteinformationsberichtes an die Basisstation ohne den aperiodischen Kanalgüteinformationsbericht mit Uplink-Shared-Channel-Daten zu multiplexen, falls die Bestimmung ein positives Ergebnis bringt.

Der Vorteil der Erfindung besteht darin, dass Informationen, die die Basisstation ohnehin an das Mobiltelefon sendet, und für die bereits Informationsfelder im Steuerkanal PDCCH vorgesehen sind, nunmehr als Trigger (Auslöser) für die unabhängige Übertragung eines Kanalqualitätsindikators dienen.

2. Der Schutzbereich eines Patents wird durch die Patentansprüche in der maßgeblichen Verfahrenssprache bestimmt (Art. 69 Abs. 1, Art. 70 Abs. 1 EPÜ). Bei der für die Beurteilung einer Patentverletzung erforderlichen Auslegung des Patentanspruchs ist der Sinngehalt des Anspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag jedes einzelnen Merkmals zu dem gesamten Leistungsergebnis der Erfindung zu ermitteln (vgl. BGH, GRUR 2016, 1031 Rn. 22 – Wärmetauscher). Wie der Durchschnittsfachmann die Kombination der Merkmale des Patentanspruchs versteht, ergibt sich ausgehend vom Patentanspruch nach dem technischen Zusammenhang seiner Merkmale unter Heranziehung der Beschreibung und Zeichnungen. Durch Heranziehung der Beschreibung zur Auslegung wird sichergestellt, dass der tatsächliche Sprachgebrauch des Patents hinreichende Beachtung findet. Der Fachmann orientiert sich hierbei an dem in der Patentschrift zum Ausdruck gekommenen Zweck der Merkmale, womit der technische Sinn der in der Patentschrift benutzten Worte und Begriffe - nicht die philologische oder logisch-wissenschaftliche Begriffsbestimmung - entscheidend ist, die Patentschrift gleichsam ihr eigenes Lexikon darstellt (vgl. BGHZ 150, 149, 156 – Schneidmesser I; BGH, GRUR 1991, 909 – Spannschraube). Die Merkmale und Begriffe des Patentanspruchs sind so zu deuten, wie dies angesichts der ihnen nach dem offenbarten Erfindungsgedanken zugedachten technischen Funktion angemessen ist (vgl. BGH, GRUR 2009, 655 – Trägerplatte). Der Patentanspruch hat Vorrang gegenüber der Beschreibung und Ausführungsbeispiele sowie die darauf bezogenen Beschreibungsteile. Sie dürfen weder zu einer inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortsinn des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen. Eine Auslegung unterhalb eines allgemeineren Sinngehalts der Ansprüche ist generell nicht zulässig (vgl. BGHZ 160, 204 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Zugleich ist die Patentschrift in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und der Patentanspruch im Zweifel so zu verstehen, dass sich keine Widersprüche zu den Ausführungen in der Beschreibung und den bildlichen Darstellungen in den Zeichnungen ergeben (BGHZ 189, 330 Rn. 24 = GRUR 2011, 701 – Okklusionsvorrichtung). Nur wenn und soweit sich die Lehre des Patentanspruchs mit der Beschreibung und den Zeichnungen nicht in Einklang bringen lässt und ein unauflösbarer Widerspruch

verbleibt, dürfen diejenigen Bestandteile der Beschreibung, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, nicht zur Bestimmung des Gegenstands des Patents herangezogen werden (BGH, GRUR 2015, 972 – Kreuzgestänge).

3. Ausgehend von diesen Grundsätzen misst die Kammer der geschützten Merkmalskombination - soweit für diesen Rechtsstreit von Interesse - den nachfolgend dargelegten Sinngehalt bei.

Das anspruchsgemäße mobile Endgerät, hat – wie im Stand der Technik bekannt – einen Empfänger, welcher ein Steuerkanalsignal empfangen kann (Merkmal 1). Und dieses Steuerkanalsignal umfasst, wie im Stand der Technik bekannt, Kanalgüteinformationsauslöser zum Auslösen einer Übertragung eines aperiodischen Kanalgüteinformationsberichts an die Basisstation (Merkmal 1.1), einen Modulations- und Codier Schema - (MSC) Index (Merkmal 1.2), welcher dem Endgerät anzeigt, welches Modulations- und Codier Schema auf dem Uplink zu verwenden ist und schließlich (Merkmal 1.3) Informationen über Ressourcenblöcke, die zur Übertragung von dem mobilen Endgerät an die Basisstation verwendet werden. Da die patentgemäße Lehre es dem Fachmann überlässt, in welcher Form die Information übertragen wird, genügt dabei, wenn sich aus einer Rückberechnung eines übertragenen Werts die Information über die Ressourcenblöcke herleiten lässt. Da im Klagepatent auch nicht zwischen virtuellen und physikalischen Ressourcenblöcken unterschieden wird, genügen auch Informationen über virtuelle Ressourcenblöcke.

Darüber hinaus enthält das mobile Endgerät einen Prozessor, der ausgelegt ist zum Bestimmen, ob der Kanalgüteinformationsauslöser gesetzt ist (Merkmal 2.1) und ob das Steuerkanalsignal einen vorbestimmten Wert des MCS-Indexes anzeigt (Merkmal 2.2) und ob das Steuerkanalsignal eine Anzahl von Ressourcenblöcken, die kleiner oder gleich einer vorbestimmten Ressourcenblockanzahl ist, anzeigt (Merkmal 2.3).

Der Sender muss darüber hinaus dahin ausgelegt sein, den aperiodischen Kanalgüteinformationsbericht an die Basisstation zu senden, ohne dass dieser zuvor mit Uplink-Shared-Channel-Daten gemultiplext wurde (Merkmal 3), falls die Vorgaben nach Merkmalsgruppe 2 bestimmt wurden.

III. Verletzung

Die angegriffenen dem LTE-Standard genügenden Mobiltelefone verwirklichen diese Lehre.

1. Die Verwirklichung der Merkmale 1, 1.1 und 1.2 ist zwischen den Parteien nicht im Streit. Dieses Verständnis beruht nicht auf patentrechtlich unrichtigen Anschauungen.

2. Entgegen der Auffassung der Beklagten hat die Klägerin anhand des LTE-Standards, von dem die angegriffenen Mobiltelefone Gebrauch machen, auch das Vorliegen von Ressourcenblockinformationen im Sinne der Merkmale 1.3 und 2.3 aufgezeigt. Die Klägerin stützt sich dabei zu Recht maßgeblich auf die Abschnitte 8.6 und 8.1 des Dokuments TS 136.213 (v.8.8.0, Anlage QE-A 24).

8.6 Modulation order, redundancy version and transport block size determination

To determine the modulation order, redundancy version and transport block size for the physical uplink shared channel, the UE shall first

- read the 5-bit "modulation and coding scheme and redundancy version" field (I_{MCS}) in the DCI, and
- check the "CQI request" bit in DCI, and
- compute the total number of allocated PRBs (N_{PRB}) based on the procedure defined in Section 8.1, and
- compute the number of coded symbols for control information..

Zu Recht sieht die Klägerin die Information über die Zahl der zugewiesenen Ressourcenblöcke in dem Wert N_{PRB}. Denn bei diesen handelt es sich nach dem vorstehend wiedergegebenen Abschnitt 8.6 um die Zahl der zugewiesenen Ressourcenblöcke („total number of allocated PRBs (N_{PRB}). Zwar wird dieser Wert nach den Vorgaben im Standard nicht unmittelbar im DCI-Format 0, also dem Steuerkanal übertragen. Jedoch hat die Klägerin vorgetragen, dass der Parameter RIV (resource information value, Ressourcen-Indikations-Wert) nach dem nachfolgend wiedergegebenen Abschnitt 8.1 an der Basisstation berechnet und dann an die Mobilstation übertragen wird.

8.1 Resource Allocation for PDCCH DCI Format 0

The resource allocation information indicates to a scheduled UE a set of contiguously allocated virtual resource block indices denoted by n_{VRB}. A resource allocation field in the scheduling grant consists of a resource indication value (RIV) corresponding to a starting resource block (RB_{START}) and a length in terms of contiguously allocated resource blocks ($L_{CRBs} \geq 1$). The resource indication value is defined by

if $(L_{CRBs} - 1) \leq \lfloor N_{RB}^{UL}/2 \rfloor$ then

$$RIV = N_{RB}^{UL}(L_{CRBs} - 1) + RB_{START}$$

else

$$RIV = N_{RB}^{UL}(N_{RB}^{UL} - L_{CRBs} + 1) + (N_{RB}^{UL} - 1 - RB_{START})$$

A UE shall discard PUSCH resource allocation in the corresponding PDCCH with DCI format 0 if consistent control information is not detected.

Danach sind die Nummer des Start-Ressourcenblocks RB_{START} und die Anzahl der ab diesem Startressourcenblock der Mobilstation zugewiesenen zusammenhängenden Ressourcenblöcke L_{CRBs} in der Formel zur Berechnung von RIV enthalten. Dies hat auch die Beklagte nicht erheblich bestritten. Soweit sie erstmals in der mündlichen Verhandlung behauptet hat, der Wert RIV sei im Steuerkanal nicht vorhanden, ergibt sich Gegenteiliges aus dem Standard. Aus Ziffer 8.1 lässt sich entnehmen, dass eine Übertragung im DCI Format 0 erfolgt.

Ohne Erfolg macht die Beklagte geltend, in Abschnitt 8.1 sei lediglich von virtuellen, nicht von physikalischen Ressourcenblöcken die Rede. Wie vorstehend unter II. 3 dargelegt, kommt es für die Merkmalsverwirklichung nicht maßgeblich darauf an, ob die Information sich auf virtuelle oder physikalische Ressourcenblöcke bezieht.

Da nach dem Vortrag der Klägerin in den angegriffenen Mobilstationen eine Rückberechnung des Wertes RIV auf den Wert N_{PRB} erfolgt, liegen dort sowohl Informationen im Sinne des Merkmals 1.3 als auch Informationen über die Anzahl der Ressourcenblöcke im Sinne des Merkmals 2.3 vor. Die Beklagte hat den Vortrag der Klägerin, wonach in den Endgeräten eine Rückberechnung der o.g. Formel erfolge, nicht mit der geforderten Substanz bestritten, er gilt deshalb nach § 138 Abs. 3 ZPO als zugestanden. Darauf wurde die Beklagte in der mündlichen Verhandlung hingewiesen.

3. Entgegen der Auffassung der Beklagten sind auch die Merkmalsgruppe 2 und das Merkmal 3 verwirklicht. Dies ergibt sich aus Ziffer 8.6.2 der zum ETSI-Standard gehörenden technischen Spezifikation TS 136213 V8.8.0 (Anlage QE-A 24), wie nachstehend wiedergegeben:

8.6.2 Transport block size determination

For $0 \le I_{MCS} \le 28$, the UE shall first determine the TBS index (I_{TBS}) using I_{MCS} and Table 8.6.1-1. The UE shall then follow the procedure in Section 7.1.7.2.1 to determine the transport block size.

For $29 \le I_{MCS} \le 31$, if $I_{MCS} = 29$, the "CQI request" bit in DCI format 0 is set to 1 and $N_{PRB} \le 4$, then there is no transport block for the UL-SCH and only the control information feedback for the current PUSCH reporting mode is transmitted by the UE. Otherwise, the transport block size shall be determined from the initial PDCCH for the same transport block using $0 \le I_{MCS} \le 28$. If there is no initial PDCCH with DCI format 0 for the same transport block using $0 \le I_{MCS} \le 28$, the transport block size shall be determined from

- the most recent semi-persistent scheduling assignment PDCCH, when the initial PUSCH for the same transport block is semi-persistently scheduled, or,
- the random access response grant for the same transport block, when the PUSCH is initiated by the random access response grant.

Aus der Vorgabe in Absatz 2 (beginnend mit „For 29...") folgt, dass kein Transportblock für den ULSCH vorhanden ist, wenn I_{MCS} (Wert des MCS-Indexes) = 29 ist, das CQI-Auslöser-Bit im DCI-Format auf 1 gesetzt und $N_{PRB} \le 4$. Ohne Erfolg macht die Beklagte geltend, aus dieser Vorgabe ergebe sich nicht, dass das Mobiltelefon den Kanalgüteinformationsauslöser, den MCS-Index und die Anzahl der Ressourcenblöcke bestimmt. Eine derartige Bestimmung sei nicht notwendig. Es reiche aus, dass das Mobiltelefon feststelle, dass es keine Daten für den Transportblock gibt. Es sei eine Vielzahl von Möglichkeiten denkbar, warum es für die besagte Kombination der genannten Werte keinen Transportblock gebe. Beispielsweise sei denkbar, dass für eine verhältnismäßig kleine Zahl von Ressourcenblöcken diese durch den Kanalgüteinformationsbericht belegt werden, so dass für die Übertragung von Uplink-Shared-Daten keine Ressourcenblöcke zur Verfügung stünden. Weiterhin sei denkbar, dass bei dieser Kombination der Parameter der Datenpuffer des Mobiltelefons leer sei. Damit ergebe sich aus dem Standard keine aktive Überprüfung der Parameter durch die Mobilstation. Nach der Überzeugung der Kammer ergibt sich nämlich aus der Vorgabe im Abschnitt 8.6.2 eine Anweisung an die Mobilstation, zu prüfen ob die dort genannten Bedingungen erfüllt sind und gegebenenfalls auf ein Multiplexing gemäß Merkmal 3 zu verzichten. Dies folgt bereits daraus, dass die empfangenen Parameter im Steuersignal enthalten sind. Unabhängig davon ergibt sich aus dem Vortrag der Beklagten nicht mit Substanz, dass eine Bestimmung im Sinne des Merkmals 2.3 und eine Reaktion nach Merkmal 3 in den von ihr vertriebenen angegriffenen Ausführungsformen unterbleibt. Darauf hat die Kammer bereits in der mündlichen Verhandlung hingewiesen.

IV. Schadensersatz und Auskunft/Rechnungslegung

Die festgestellten patentverletzenden Handlungen rechtfertigen nach Maßgabe der nationalen Bestimmungen (Art. 64 Abs. 1, Abs. 3, Art. 2 Abs. 2 EPÜ) die gestellten Anträge, soweit sie auf Auskunftserteilung/Rechnungslegung sowie die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gerichtet sind.

1. Antragsgemäß ist festzustellen, dass die Beklagte für Handlungen seit dem festgestellten Zeitpunkt zum Ersatz des hieraus der Klägerin und ihrer Rechtsvorgängerin entstandenen Schadens verpflichtet ist, § 139 Abs. 2 PatG. Die besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Feststellungsklage nach § 256 Abs. 1 ZPO liegen vor. Die Klägerin kennt den genauen Umfang der Verletzungshandlungen nicht und kann ohne diese Kenntnis einen Antrag auf Zahlung von Schadensersatz nicht beziffern. Die Klägerin hat - auch zur Hemmung der Verjährung und Herbeiführung der dreißigjährigen Verjährungsfrist - ein rechtliches Interesse daran, dass das Bestehen eines Ersatzanspruchs alsbald festgestellt wird. Im gewerblichen Rechtsschutz steht der grundsätzliche Vorrang der Leistungsklage auch bei Möglichkeit einer Stufenklage im Sinne des § 254 ZPO einer Feststellungsklage unter prozessökonomischen Gesichtspunkten nicht entgegen (vgl. BGH, GRUR 2003, 900 – Feststellungsinteresse III). Die Beklagte hat nach dem Klagevorbringen schuldhaft, nämlich zumindest fahrlässig gehandelt. Bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt (§ 276 Abs. 2 BGB) hätte im Geschäftsbetrieb der Beklagten spätestens einen Monat nach Veröffentlichung der Mitteilung über die Erteilung des Klagepatents grundsätzlich erkannt werden können und müssen, dass das Klagepatent durch den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen verletzt wird.

2. Ausgehend hiervon ist die Beklagte der Klägerin hinsichtlich der tenorierten schutzrechtsverletzenden Benutzungshandlungen im Inland ferner zur Auskunft - wegen der Unabhängigkeit von einem Verschuldensmoment frühestens ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Hinweises auf Erteilung des Klagepatents - und zur Rechnungslegung - frühestens ab einen Monat nach diesem Zeitpunkt - verpflichtet gemäß § 140b Abs. 1, Abs. 3 PatG und einer zu Gewohnheitsrecht erstarkten Anwendung von § 242 BGB (vgl. BGH, GRUR 1980, 227, 232 – Monumenta Germaniae Historica; BGHZ 125, 322 [326] = GRUR 1994, 630, 631 f – Cartier-Armreif). Die Klägerin kennt die zur Bezifferung ihrer Ansprüche notwendigen

Einzelheiten ohne eigenes Verschulden nicht; demgegenüber wird die Beklagte durch die Erteilung der ihr abverlangten Auskünfte nicht unverhältnismäßig belastet und kann sie auch ohne Schwierigkeiten geben. Der Anspruch besteht hinsichtlich aller tenorierten, möglichen Benutzungshandlungen, auch soweit diesbezüglich kein konkreter Vortrag der Klägerin geleistet worden ist (vgl. BGH, GRUR 1960, 423, 424 – Kreuzbodenventilsäcke).

3. Den geltend gemachten Ansprüchen kann die Beklagte unter dem Gesichtspunkt des sog. Patenthinterhalts („Patent Ambush") einen Arglisteinwand nicht mit Erfolg entgegenhalten.

Die Voraussetzungen etwaiger die Rechtsdurchsetzung der Klägerin hindernder Ansprüche aus § 33 GWB, Art. 102 AEUV oder aus § 826 BGB sind bereits ungeachtet der Frage, ob und unter welchen Umständen ein arglistiges Verhalten der Patentanmelderin auch Erwerbern des Patents entgegengehalten werden könnte, nicht dargetan.

Es kann dahin gestellt bleiben, ob - wie die Beklagte meint - Rechtsfolge eines „Patenthinterhaltes" die Verpflichtung der Klägerin wäre, Dritten Freilizenzen zu gewähren (dagegen unter Hinweis auf § 249 BGB: LG Düsseldorf, Urteil vom 07.06.2011 - Az. 4BO3110 4b O 31/10, Juris Rn. 84f. m. w. N.) und dies nicht nur die - die geltend gemachten Ansprüche nicht hindernde - Folge haben kann, dass eine Verpflichtung zur Lizenzierung zu FRAND-Konditionen besteht.

Soweit sich die Beklagte auf den Vorwurf stützt, die Rechtsvorgängerin der Klägerin habe die Anmeldung des Klagepatents entgegen den Vorgaben der ETSI-Policy im Standardisierungsverfahren bewusst nicht offengelegt, genügt dies für sich noch nicht.

Zwar kann nach Auffassung der Kammer unter bestimmten Voraussetzungen das Vorgehen des - auch zu FRAND-Bedingungen lizenzierungsbereiten - Patentinhabers aus einem standardessentiellen Patent gegen das aus Art. 102 AEUV folgende Missbrauchsverbot verstoßen (vgl. KOM, Entscheidung v. 09.12.2009, COMP/38.636, WuW 2010, 719 ff). Indessen wird unter Berücksichtigung des auch im Unionsrecht anerkannten und zu schützenden Grundrechts des geistigen Eigentums ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung des Inhabers standardessentieller Patente trotz dessen Bereitschaft, Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, nur in

Ausnahmefällen festgestellt werden können, in denen durch FRAND-Lizenzen den Wettbewerbszielen der Europäischen Union und der sie gründenden Verträge nicht mehr Geltung zu verschaffen wäre. Ein solcher Fall kann nach der genannten Entscheidung der Europäischen Kommission dann angenommen werden, wenn der an der Standardisierung beteiligte Patentinhaber das Standardisierungsverfahren bewusst - im Sinne „vorsätzlichen betrügerischen Handelns" - hintertreibt und eine andere, von der patentgemäßen Erfindung abweichende, technische Spezifikation bewusst vereitelt. Erst dann kann das Bestehen des Patentinhabers auf FRAND-Lizenzen als Missbrauch der ihm durch die Patenterteilung und Standardisierung zugewachsenen marktbeherrschenden Stellung bewertet werden.

Voraussetzung für den Missbrauch wäre hiernach (vgl. KOM, Entscheidung v. 09.12.2009, COMP/38.636, WuW 2010, 719 ff) zunächst, dass eine Offenlegung im Standardisierungsverfahren zu einer abweichenden, nicht die klagepatentgemäße technische Lehre nutzenden Ausgestaltung des Standards geführt haben könnte, wofür die Beklagte darlegungsbelastet ist. Diese trägt nicht vor, welche technische Lösung an Stelle der in den Standard übernommenen technischen Lehre in Betracht gekommen wäre. Entgegen der Auffassung der Beklagten ist ihr solcher Vortrag auch zumutbar. Denn der insoweit relevante Stand der Technik lässt sich ohne weiteres ermitteln. Nur in dem Fall, in dem es überhaupt eine alternative Lösung gab, stellt sich die Frage, ob dem Patentinhaber, welcher in Person oder in Person seines Rechtsvorgängers an dem Standardisierungsprozess beteiligt war, eine sekundäre Darlegungslast zur Frage obliegt, ob die alternative Lösung in Betracht gezogen worden wäre. Die bloße theoretische Möglichkeit einer anderweitigen Lösung genügt - auch ohne Berücksichtigung der Tatsache, dass sich die Teilnehmer der den Standard beratenden Arbeitsgruppe trotz der damit verbundenen FRAND-Lizenz auch für eine von ihnen als vorteilhafter erachtete patentgeschützte technische Lehre entscheiden können - nicht. Daher besteht für die Kammer auch kein Anlass, die Frage der Rechtsfolge eines Patenthinterhaltes dem Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Art. 267 Abs. 2 AEUV zur Vorabentscheidung vorzulegen.

4. Der Urteilsausspruch zu den zuerkannten Anträgen unterliegt keiner Beschränkung im Hinblick auf den von der Beklagten erhobenen kartellrechtlichen Missbrauchseinwand.

a) Die Durchsetzbarkeit der Ansprüche auf Auskunft / Rechnungslegung sowie Schadensersatz dem Grunde nach bleibt auch bei einer FRAND-Selbstverpflichtungserklärung des SEP-Inhabers unberührt (vgl. Huawei Technologies/ZTE: EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 72 ff. = ECLI:EU:C:2015:477 idF des Berichtigungsbeschlusses vom 15. Dezember 2015, ECLI:EU:C:2015:817; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30. März 2017 - I-15 U 66/15, Rn. 226 - juris).

b) Es kann im Rahmen der Feststellung der Schadensersatzpflicht (dem Grunde nach) dahinstehen, ob in der konkreten Fallkonstellation der Schadensersatz der Höhe nach - insbesondere für sämtliche in Betracht zu ziehenden Zeiträume - tatsächlich auf dasjenige beschränkt ist, was sich in Anwendung der Schadensausgleichsmethodik „Lizenzanalogie" auf Basis einer FRAND-Lizenzgebühr ergibt (anders wohl: OLG Düsseldorf aaO Rn. 236). Denn für den Erfolg des Klagebegehrens genügt es festzustellen, dass aufgrund der patentverletzenden Handlungen überhaupt ein Schaden wahrscheinlich entstanden ist, ohne dass Feststellungen zu dessen Höhe geboten sind (Kammer GRUR-RR 2018, 273 Rn. 72 – Funkstation).

c) Anders als das Oberlandesgericht Düsseldorf in seiner Entscheidung vom 30. März 2017 (aaO Rn. 243 ff.) vertritt, ist eine inhaltliche Beschränkung des Auskunfts- / Rechnungslegungstenors nach Auffassung der Kammer im Grundsatz ebenso wenig veranlasst. Hierbei kann wiederum dahinstehen, ob der Verletzte beim Schadensersatz der Höhe nach auf eine FRAND-Lizenzgebühr beschränkt ist, namentlich also nicht nach der Methode „Verletzergewinn" seinen Schaden liquidieren kann. Denn selbst bei einer Beschränkung des Schadensersatzanspruchs kann der Verletzte in der hiesigen Konstellation die vorliegend geforderten Daten im Rahmen der Rechnungslegung grundsätzlich fordern (im Einzelnen: Kammer GRUR-RR 2018, 273 Rn. 76 – Funkstation).

V. Derzeit unbegründete weitergehende Ansprüche

Die Klage ist als derzeit unbegründet abzuweisen, soweit die Klägerin von der Beklagten Unterlassung, Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen sowie die Vernichtung patentverletzender Produkte nach Art. 64 Abs. 3 EPÜ iVm § 139 Abs. 1, § 140a Abs. 1, Abs. 3 PatG begehrt. Der gerichtlichen Durchsetzung steht Art. 102 AEUV und § 19 Abs. 1 GWB entgegen. Nach der Entscheidung des Unionsgerichtshofs in der Rechtssache Huawei./. ZTE missbraucht der Inhaber eines für einen von einer

Standardisierungsorganisation normierten standardessenziellen Patents, der sich gegenüber dieser Organisation unwiderruflich verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen (FRAND-Bedingungen) zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung, wenn er Klage auf Unterlassung der Beeinträchtigung des Patents oder auf Rückruf der patentgemäßen Produkte erhebt, ohne vor Erhebung der Klage den vom Unionsgerichtshof genannten Obliegenheiten zu genügen (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 = ECLI:EU:C:2015:477 idF des Berichtigungsbeschlusses vom 15. Dezember 2015, ECLI:EU:C:2015:817).

1. Der kartellrechtliche Missbrauchseinwand kann der Klägerin entgegengehalten werden.

a) Denn die Klägerin verfügt als Inhaberin des Klagepatents über eine marktbeherrschende Stellung und ist hiernach Normadressatin nach Art. 102 AEUV und § 19 Abs. 1 GWB. Die Beklagte hat unwidersprochen vorgetragen, dass es weder eine nachfrager- noch anbieterseitige Substituierbarkeit der LTE-Technologie gebe. Der LTE-Standard kann nicht durch einen anderen Standard einer früheren Generation ersetzt werden. Denn LTE bietet eine wesentlich schnellere Datenübertragung. Damit hat die Beklagte schlüssig aufgezeigt, dass die Nutzung des Klagepatents eine Marktzutrittsvoraussetzung begründet. Das Klagepatent ist essentiell für den LTE-Standard. Damit kommt der Klägerin eine marktbeherrschende Stellung zu.

b) Die ursprüngliche Patentinhaberin. P hat sich gegenüber ETSI, der Standardisierungsorganisation, die den streitgegenständlichen LTE-Standard entwickelt und ausgegeben hat, unwiderruflich zur Erteilung einer FRAND-Lizenz gemäß „Clause 6.1 of the ETSI Policy" verpflichtet (Anlage HL (A) 6 S. 12 ff.). Ziffer 6.1 der ETSI Rules of Procedures sieht insoweit vor (Unterstreichung hinzugefügt):

„transfer of ownership of ESSENTIAL IPR
FRAND licensing undertakings made pursuant to Clause 6 shall be interpreted as encumbrances that bind all successors-in-interest. Recognizing that this interpretation may not apply in all legal jurisdictions, any Declarant who has submitted a FRAND undertaking according to the POLICY who transfers ownership of ESSENTIAL IPR that is subject to such undertaking shall include appropriate provisions in the relevant transfer documents to ensure that the undertaking is binding on the transferee and that the transferee will similarly include appropriate provisions in the event of future transfers with the goal of binding all successors-

in-interest. The undertaking **shall be interpreted as binding on successors-in-interest** regardless of whether such provisions are included in the relevant transfer documents."

(1) Aus der Regelung ergibt sich eine Vermutung für eine Bindung auch des Erwerbers des Patents. Da die Klägerin selbst davon ausgeht, dass sie die FRAND-Obliegenheiten zu erfüllen hat, bedurfte es keines weitergehenden Vortrags der Beklagten.

(2) Selbst wenn die Klägerin eine entsprechende Verpflichtung nicht übernommen hätte, ergäben sich aus der FRAND-Selbstverpflichtung ihrer Rechtsvorgängerin kartellrechtliche Verhaltenspflichten. Denn die FRAND-Selbstverpflichtung soll sicherstellen, dass die für eine Standardisierungsnorm wesentliche patentierte Technologie den Anwendern dieser Standardisierungsnorm zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen zugänglich ist. So können die Patentinhaber durch die FRAND-Selbstverpflichtungen insbesondere davon abgehalten werden, dass sie die Anwendung einer Norm erschweren, indem sie die Lizenzerteilung ablehnen oder unfaire bzw. unangemessene (d.h. überhöhte) Gebühren verlangen, nachdem sich die Branche der Standardisierungsnorm angeschlossen hat (Mitteilung der Europäischen Kommission, Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit, ABl. C 11, S. 1, 60 Rn. 287, fortan: Horizontalleitlinie). Eine Wettbewerbsbeschränkung durch eine Normenvereinbarung im Sinne des Art. 101 Abs. 1 AEUV bzw. § 1 GWB wird auf diese Weise verhindert. Die Normenorganisation genügt der Einhaltung von Art. 101 AEUV bzw. § 1 GWB bereits dadurch, dass sie FRAND-Erklärungen der Patentinhaber einholt und diese verpflichtet, dass auch Unternehmen, an die die Patentinhaber ihre Rechte des geistigen Eigentums übertragen, an diese Verpflichtung gebunden werden (Horizontalleitlinie Rn. 285 und Rn. 288). Sie ist nicht verpflichtet, die Einhaltung der FRAND-Verpflichtung zu überprüfen (Horizontalleitlinien Rn. 288). Vor diesem Hintergrund missbraucht der Rechtsnachfolger des SEP-Inhabers seine marktbeherrschende Stellung, wenn er sich in Kenntnis der FRAND-Selbstverpflichtung seines Rechtsvorgängers weigert, die sich daraus ergebenden Pflichten und Obliegenheiten zu erfüllen. Denn die Geltendmachung des SEP – eines Sperrpatents – führt in diesem Fall zu einer von der Rechtsordnung nicht hinzunehmenden Wettbewerbsbeschränkung. Ein Missbrauch im Sinne des § 19 Abs. 1 GWB ist deshalb zu bejahen, weil das Vorgehen des SEP-Inhabers sich in diesem Fall im Lichte der Wertungen des Kartellrechts als nicht mehr interessengerecht

darstellt (vgl. Langen/Bunte/Nothdurft, GWB, 13. Aufl. § 19 GWB Rn. 129). Er will die Vorteile der Standardisierung für sich in Anspruch nehmen, ohne dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Aufnahme der patentierten Technologie in den Standard ohne die Selbstverpflichtung seines Rechtsvorgängers aus Gründen des Kartellrechts nicht möglich gewesen wäre.

2. Die Klägerin ist den FRAND-Obliegenheiten nicht nachgekommen. Hiernach muss der Inhaber eines SEPs, bevor er Ansprüche auf Unterlassung und Rückruf im Wege der Klage geltend macht, den angeblichen Verletzer auf die Patentverletzung hinweisen (EuGH GRUR 2015, 764 Rn. 61) und, nachdem der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, diesem ein konkretes schriftliches Lizenzvertragsangebot zu FRAND-Bedingungen (fair, reasonable, and non-discriminitory) unterbreiten und insbesondere die Lizenzgebühr und die Art und Weise ihrer Berechnung angeben (EuGH GRUR 2015, 764 Rn. 63). Nimmt der angebliche Verletzer das ihm unterbreitete Angebot nicht an, kann er sich auf den missbräuchlichen Charakter einer Unterlassungs- oder Rückrufklage nur berufen, wenn er dem Inhaber des betreffenden SEP innerhalb einer kurzen Frist schriftlich ein konkretes Gegenangebot macht, das den FRAND-Bedingungen entspricht (EuGH GRUR 2015, 764 Rn. 66). Letzteres impliziert, dass dem angeblichen Patentverletzer vor Erhebung der Klage die Möglichkeit gegeben werden muss, innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf das Angebot des Patentinhabers zu reagieren.

   a) Ihre Obliegenheiten haben beide Parteien auf der ersten Stufe erfüllt. Die Klägerin hat mit dem an die Muttergesellschaft der Beklagten gerichteten Schreiben vom 29. Februar 2016 (Anlage HE-A 11/HE-A 11a) mittels eines Claim Charts dargetan, dass die im LTE-Standard patentierte Technologie von dem Klagepatent Gebrauch macht. Dass der Hinweis an die Konzernmuttergesellschaft der Beklagten gerichtet war, schadet nicht (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR 2017, 1219 – Mobiles Kommunikationssystem; Kammer GRUR-RR 2018, 273 Rn. 83 - Funkstation). Die Muttergesellschaft der Beklagten hat darauf ihre grundsätzliche Lizenzbereitschaft zum Ausdruck gebracht, indem sie mit der Klägerin in Verhandlungen eintrat. Eine entsprechende Bereitschaftserklärung findet sich u.a. in dem Schreiben der Muttergesellschaft vom 7. September 2016 (Anlage HL (A) Kart 3).

b) Damit oblag es der Klägerin auf der zweiten Stufe, ein FRAND- Angebot zu unterbreiten und insbesondere die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr anzugeben (EuGH aaO. Rn. 63), um die Beklagte in die Lage zu versetzen, auf das Angebot sorgfältig und ernsthaft, insbesondere ohne Verzögerungstaktik zu reagieren (EuGH aaO. Rn. 65). Zwischen den Parteien steht nicht im Streit, dass das erste Angebot der Klägerin vom 3. August 2015 den FRAND-Vorgaben nicht genügte. Auch das Angebot vom 29. Februar 2016 genügte den FRAND-Vorgaben nicht. Denn Ziffer 5.6.1 des Vertragsentwurfes lässt eine Beurteilung des Angebots als fair und angemessen nicht zu. Danach soll zwischen den Parteien Einigkeit bestehen, dass es für die Verpflichtung zur Zahlung der vollen Lizenzgebühr genügt, wenn nur eines der Patente des Portfolios rechtsbeständig ist und benutzt wird. Damit wird in unangemessener Weise der Beklagten das Risiko der Rechtsbeständigkeit der Patente auferlegt (vgl. LG Mannheim Urt. v. 23.05.2017 – Az. 2 O 98/16, S. 36 – nicht veröffentlicht). Das Angebot vom 21. April 2017 wurde in diesem Verfahren nicht vorgelegt. Da die Klägerin es als überholt bezeichnet, kann nicht angenommen werden, dass es den FRAND-Vorgaben entsprach.

c) Maßgeblich ist damit auf das FRAND-Angebot vom 16. Februar 2018 abzustellen. Es kann dahinstehen, ob dieses vor der Klageerweiterung gemachte Angebot den FRAND-Vorgaben genügte. Denn unabhängig davon stellt die Klageerweiterung einen Missbrauch nach Art. 102 AEUV bzw. § 19 Abs. 1 GWB dar. Die Klägerin hatte der Beklagten vor der Klageerweiterung keine angemessene Frist eingeräumt, um das Angebot zu prüfen und ein Gegenangebot abgeben zu können. Dass eine Reaktion der Beklagten zum Zeitpunkt der Klageerweiterung noch nicht vorlag, rechtfertigt deshalb auch nicht die Annahme, dass die Erklärung der Lizenzbereitschaft nicht ernst gemeint war und die Beklagte bzw. ihre Muttergesellschaft eine Verzögerungstaktik verfolgte (vgl. EuGH aaO Rn. 88).

Für die Beurteilung der Angemessenheit der Frist ist auf den 11. April 2018 abzustellen. Denn erst zu diesem Zeitpunkt war das Angebot der Klägerin nach den Vorgaben des Unionsgerichtshofs vollständig. Der Patentinhaber hat die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr so anzugeben, dass hierin deutlich wird, aus welchen darzulegenden Gründen er von einer Erfüllung der FRAND-Kriterien ausgeht (Kammer, Urt. v. 01.07.2016 – 7 O 209/15, S. 26; Urt. v. 19.08.2016 - 7 O 19/16 S. 21 und Urt. v. 19.08.2016 – 7 O 238/15 – nicht

veröffentlicht; Urt. v. 16.12.2016 – 7 O 29/16 und 6 U 32/16; GRUR-RR 2018, 273 Rn. 84 - Funkstation). Insoweit muss er den Betrag gegenüber dem vermeintlichen Verletzer in geeigneter Weise transparent bzw. plausibel machen, etwa durch Vortrag zu einem in der Vertragspraxis gelebten und von Dritten akzeptierten Standardlizenzprogramm oder unter Heranziehung anderer Bezugsgrößen, aus dem die geforderte Lizenzgebühr abgeleitet wird, wie etwa aus einer Poollizenzgebühr, die in der Praxis für den Patentpool von Dritten gezahlt wird, der auch für den fraglichen Standard relevante Patente umfasst (Kammer, GRUR-RR 2018, 273 Rn. 84 - Funkstation). Um dem angeblichen Patentverletzer die Überprüfung zu ermöglichen, dass der SEP-Patentinhaber seiner Pflicht zur Gleichbehandlung genügt, ist darüber hinaus erforderlich, dass konkret zu den mit Dritten geschlossenen Lizenzverträgen vorgetragen wird (vgl. OLG Düsseldorf BeckRS 2016, 21067 Rn. 22; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 10. Aufl. Kap. E Rn. 311; Europäische Kommission, Mitteilung über den Umgang der EU mit standardessenziellen Patenten, COM(2017) 712 S. 12). Diese Angaben haben nicht nur den Zweck, den Patentbenutzer in die Lage zu versetzen, einzuschätzen, ob das Angebot tatsächlich FRAND ist. Vielmehr erhöht die Transparenz die Chance, dass die Parteien miteinander ins Gespräch kommen und konstruktiv über die Frage der Lizenzhöhe diskutieren können (vgl. Kammer, Urt. v. 16.12.2016 – 7 O 32/16, S. 36).

Die Beklagte bzw. deren Muttergesellschaft verfügte damit erst mit der Zurverfügungstellung der Drittlizenzverträge am 11. April 2018 über die relevante Information, die eine Reaktionspflicht ihrerseits in angemessener Frist auslöste. Weder die von der Klägerin gesetzten Frist von einer Woche (18. April 2018), die verlängerte Frist von nicht einmal vier Wochen (7. Mai 2018) noch die Zeit bis zur Einreichung der Klageerweiterung am 15. Mai 2018 waren ausreichend, um der Beklagten eine sorgfältige Überprüfung der Frage zu ermöglichen, ob das Lizenzvertragsangebot gegen das Diskriminierungsverbot verstößt. Der Beklagten wurden drei Drittlizenzverträge zur Verfügung gestellt, die sie darauf untersuchen musste, ob die Konditionen von den ihr angebotenen Konditionen abwichen und hierfür ein sachlicher Grund bestand. Insbesondere war ein Vergleich der jeweils lizenzierten Patente erforderlich, was bei 44 Patentfamilien (vgl. Anlage QE-A 8 Schedule A) einen erheblichen Zeitaufwand bedeutet. Nach der Analyse bedurfte es einer konzerninternen Abstimmung und der Einbindung der maßgeblichen Entscheidungsträger in den Entscheidungsprozess. Hierfür reichte bei objektiver

Betrachtung der Zeitraum von 22 Werktagen bei weitem nicht aus. Ein weiteres Zuwarten war der Klägerin auch zumutbar. Wie die Verhandlungshistorie zeigt, hat die Klägerin selbst einige Zeit benötigt, um das Angebot vom 16. Februar 2018 vorzulegen. Ihr letztes Angebot datierte vom 21. April 2017. Die Lizenzverträge mit Dritten wurden am 29. September 2017 ([...]) bzw. am 21. Juni 2017 ([...]) geschlossen. Auch die Verfasser des Angebots vom 16. Februar 2018 gingen offensichtlich davon aus, dass die Prüfung des Vertrages einige Zeit in Anspruch nimmt. Denn in Schedule B heißt es: „Tables in this Schedule B are conditional upon execution of the Agreement as of June 30, 2018" (Die Tabellen in dieser Anlage B stehen unter der Bedingung der Unterzeichnung bis zum 30. Juni 2018).

d) Der Zeitraum, der der Beklagten bzw. ihrer Muttergesellschaft bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung am 13. Juli 2018 zur Verfügung stand, wäre zwar grundsätzlich ausreichend gewesen, um der Beklagten eine sorgfältige Prüfung des Angebots zu ermöglichen. Dies ändert jedoch nichts an der Missbräuchlichkeit der Klageerweiterung.

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung des Rechtsstreits ist zwar der Schluss der letzten mündlichen Verhandlung (vgl. § 296a ZPO; Beck OK ZPO/Bacher ZPO § 296a Rn. 1). Jedoch ist zu berücksichtigen, dass das vom Unionsgerichtshof festgelegte Verhaltensprogramm deshalb vor Erhebung der Klage auszuführen ist, weil damit vermieden werden soll, dass der angebliche Verletzer unter dem Druck einer drohenden Verurteilung ungünstigen Lizenzbedingungen zustimmt (sog. Patent Hold-up; vgl. Schlussanträge des Generalanwalts Wathelet, vom 29.11.2014, C 170/13 Rn. 102; Europäische Kommission, Mitteilung über den Umgang der EU mit standardessenziellen Patenten, COM (2017) 712 S 12). Dieser Druck ist besonders hoch, wenn die Klage auf Unterlassung, Vernichtung und Rückruf bereits erhoben ist. Dies gilt in besonderem Maße, wenn – wie hier – zwischen Klageerweiterung (15. Mai 2018) und mündlicher Verhandlung (13. Juli 2018) etwa acht Wochen liegen. Eine drucklose Verhandlungssituation ist nicht gewährleistet, wenn die Parteien sich an gerichtlich gesetzte Fristen halten müssen. Auch eine Moderation durch das Verletzungsgericht kann eine druckfreie Verhandlungssituation nicht sicherstellen (aA Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 10. Aufl., Kap. E Rn. 361). Denn die Parteien sind am besten in der Lage, im Rahmen von ernsthaft geführten Verhandlungen eine Einigung darüber zu erzielen, was faire Lizenzbedingungen und Gebührensätze sind

(Europäische Kommission aaO S. 7). Es mag zwar sein, dass das Gericht durch gerichtliche Hinweise und mit Hilfe von Schriftsatzfristen die Parteien zu zügigem Verhalten anleiten kann. Jedoch ist es gerade diese Prozess- bzw. Drucksituation, vor der der mutmaßliche Verletzer geschützt werden soll. Erhebt der SEP-Inhaber Klage, ohne zuvor den aus der FRAND-Verpflichtungserklärung sich ergebenden Obliegenheiten zu genügen, bleibt die Klageerhebung missbräuchlich, wenn und solange sich der SEP-Inhaber nicht um eine drucklose Verhandlungssituation bemüht. Eine solche Verhandlungslage bietet das Prozessrecht im Rahmen der Ruhendstellung eines Rechtsstreits zum Zwecke von Vergleichsverhandlungen nach § 251 ZPO. Die Klägerin, der die Überlegungen der Kammer in diese Richtung bekannt waren (vgl. SS v. 06.07.2018, S. 7), wäre danach gehalten gewesen, das Ruhen des Verfahrens zu beantragen, um zu einer druckfreien Verhandlungssituation zurückzukehren (vgl. Kammer GRUR-RR 2018, 273 Rn. 87 – Funkstation). Dem ist sie nicht nachgekommen. Im nachgelassenen Schriftsatz vom 24. August 2018 (S. 11) hat die Klägerin lediglich für den Fall, dass das mit diesem Schriftsatz eingeführte Angebot vom 27. Juli 2018 nicht mehr berücksichtigt werden kann, das Ruhen des Verfahrens angeregt.

VI. Keine Aussetzung

Die von der Beklagten erhobene Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent gebietet eine nach § 148 ZPO ins Ermessen der Kammer gestellte Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits nicht.

1. Die Aussetzungsentscheidung erfordert eine Abwägung des mit dem Interesse der beklagten Partei übereinstimmenden Interesses an widerspruchsfreien Entscheidungen im Verletzungs- und Rechtsbestandsverfahren gegenüber dem Interesse des Verletzungsklägers an einem zeitnahen Abschluss des Verletzungsverfahrens (vgl. BGHZ 158, 372, 376 – Druckmaschinen-Temperiersystem I). Da der Verletzungsrichter an den Erteilungsakt gebunden ist, kommt eine Suspendierung der aus dem erteilten Patent folgenden Ausschließlichkeitsbefugnisse nur unter besonderen Umständen in Betracht. Regelmäßig erforderlich, aber zur Gewährung effektiven Rechtsschutzes für den Verletzungsbeklagten auch genügend ist es, den Rechtsstreit auszusetzen, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent dem

erhobenen Rechtsbestandsangriff nicht standhalten wird (vgl. BGH, GRUR 2014, 1237, 1238 – Kurznachrichten).

2. Gemessen an diesem Maßstab hat es die Beklagte nicht vermocht, der nicht fachmännisch besetzten Kammer aufzuzeigen, dass zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit des Erfolgs ihrer Nichtigkeitsklage in dem Sinne besteht, dass das Klagepatent zumindest nicht mit dem erteilten, der Verletzungsklage zugrundeliegenden Schutzbereich Bestand haben wird.

   a) Es bestehen Zweifel, ob die Entgegenhaltung EP 2 242 303 A 2 gemäß Anlage K 19 zur Nichtigkeitsklage (fortan: NK 19) zum Stand der Technik gehört. Dies hängt davon ab, ob die Entgegenhaltung die vor dem Prioritätstag des Klagepatents liegende Priorität der US 61/25,808 vom 3. Februar 2008 (Anlage HE-A 23, englische Übersetzung Anlage HE-A 23a) zu Recht in Anspruch nimmt.

      Die Beklagten haben nicht aufzuzeigen vermocht, dass die US 61/25,808 die Möglichkeit offenbart, in Abhängigkeit von den in den Merkmalen 2.1 bis 2.3 des Klagepatents genannten Bedingungen einen nicht gemultiplexten aperiodischen Kanalgüteinformationsbericht (CQI) zu senden. Dort ist lediglich im Abschnitt 2.1 offenbart, dass der aperiodische CQI mit Daten, falls vorhanden, gemultiplext wird.

   b) Soweit die Beklagte dem geltend gemachten Anspruch die fehlende Erfindungshöhe absprechen möchte, sieht die Kammer ebenfalls von einer Aussetzung ab. Die Beklagte verweist insoweit auf die als Anlage K 17 (3GPP TSG-RAN WG 1 Meeting #53 von P) und Anlage K 26 (3GPP TSG RAN WG1#53 von Motorola) jeweils zur Nichtigkeitsklage vorgelegten Beiträge von Unternehmen, die bei Standardisierungsmeetings vorgestellt wurden, und das allgemeine Fachwissen. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Beklagten im Nichtigkeitsverfahren hinreichend wahrscheinlich der Nachweis gelingt, dass die Beiträge bereits vor dem jeweiligen Meeting (am 14. Mai 2008 bzw. 6. Mai 2008) und damit vor dem Prioritätstag veröffentlicht wurden. Die Beklagte hat für ihre Behauptung, es sei üblich, Beiträge bereits vor dem Meeting zirkulieren zu lassen, lediglich Sachverständigengutachten angeboten. Dies begründet keine hinreichende Vernichtungswahrscheinlichkeit.

c) Es ist auch nicht in dem erforderlichen Maß wahrscheinlich, dass die Nichtigkeitsklage unter dem Gesichtspunkt einer unzulässigen Erweiterung Erfolg haben wird.

(1) Im Erteilungsverfahren wurde das im ursprünglichen Anspruch 12 vorhandene Teilmerkmal „predetermined transport format" durch die Kombination zweier Elemente, nämlich "a Modulation and Coding Scheme, MCS, Index" (Merkmal 1.2) und "information on resource blocks used for the transmission from the mobile terminal to the base station" (Merkmal 1.3 und Merkmal 2.3) im erteilten Anspruch 9 ersetzt. Ohne Erfolg macht die Beklagte geltend, die genannten Merkmale seien nicht ursprungsoffenbart gewesen. Denn die Offenbarung ergibt sich aus den Erläuterungen auf Seite 20 der ursprünglichen Anmeldeunterlagen (Anlage K 2 in Anlagenkonvolut HL (A) 8). Dort wird erläutert, dass das "modulation and coding scheme" ein "transport format" im Sinne der Patentanmeldung ist.

„It should be noted that for simplicity it is referred to transport format and redundancy version in most of the examples herein. However, in all embodiments of this invention the term "transport format" means either one of "transport format", "transport block size" ... or "**modulation and coding scheme**."

Weiter wird ausgeführt, dass neben dem „transport format (e.g MCS index)" und dem „CQI trigger" weitere Parameter vorgesehen sein können (Anlage K 2 des Anlagenkonvoluts HL (A) 8 S. 22):

„The basic idea of the invention is further extensible by using other conditional parameter values additionally to the transport format (e.g. MCS Index) and COI trigger."

Dass es sich bei der Anzahl der Ressourcenblöcke um einen solchen Parameter handelt, ergibt sich aus folgenden Ausführungen (aaO. S. 22):

„The control channel signal controls information on resource blocks used for the transmission from the terminal to the base station on the PUCCH. The transmission of the channel quality Indicator CQI using the predetermined mode defined above is to be triggered by the terminal only in case the information on the resource blocks indicates a number of ressource blocks thal is smaller or equal to a predetermined resource block number".

(2) Aus dem Gesamtinhalt der Ursprungsanmeldung (aaO. S. 20) ergibt sich auch die Offenbarung von Merkmal 3, wenn dort ausgeführt wird:

„The control channel signal further comprises a CQI trigger signal for triggering a transmission of a CQI by the terminal. The interpretation of the selected transport format by the terminal depends on the status of one or more CQI trigger bits in the CQI trigger signal comprised in the control channel signal. In case the CQI trigger signal indicates to the terminal to transmit a CQI report and the value of transport format parameter corresponds to the predetermined value, the terminal interprets this combination as a command to transmit such CQI in the predetermined mode, i.e. here the CQI-only mode, to the base station. If, on the other hand, the value of transport format parameter does not correspond to the predetermined value, even if CQI trigger is set, the terminal will interpret the CQI trigger as well as the transport format parameter in their usual meaning."

VII. Nebenentscheidungen

Die Nebenentscheidungen zu Kosten und vorläufiger Vollstreckbarkeit folgen aus § 92 Abs. 1, § 269 Abs. 3 S. 2, § 709 ZPO.

[...]	Richter am Landgericht [...]	[...]
Vorsitzende Richterin am Landgericht	ist urlaubsbedingt an der Unterzeichnung verhindert	Richter am Landgericht

[...]

Vorsitzende Richterin
am Landgericht

Verkündet am 28.09.2018

[...]
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle